RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.519 - SP (2018/0023436-5)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE	:	ESSER ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO	:	MAURICIO OZI E OUTRO(S) - SP129931
RECORRIDO	:	MARIA JOSE DANIELI LEITE
RECORRIDO	:	PAULO SERGIO DANIELI LEITE
ADVOGADO	:	JOÃO LUCIO NIEDZIELSKI LEITE E OUTRO(S) - SP306038

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).

2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).

4. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Moura Ribeiro com parcial ressalva de entendimento, no que foi acompanhado pelos

Srs. Ministros Nancy Andrighi e Marco Aurélio Bellizze, a Segunda Seção, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Marco Aurélio Bellizze acompanharam o Sr. Ministro Moura Ribeiro por parcial ressalva de ponto de vista.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 28 de agosto de 2019(Data do Julgamento)

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.519 - SP (2018/0023436-5)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial interposto por ESSER ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 315):

> APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Contrato de compromisso de compra e venda. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Contrato regido pelo CDC. É direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda, assumido o ônus da rescisão, porquanto, ainda que o contrato faça lei entre as partes, não se pode impor a ninguém ficar eternamente vinculado. Retenção de 10% do valor pago pelos autores. Quantia que se mostra suficiente para compensar os custos operacionais oriundos do desfazimento do negócio jurídico. Precedentes jurisprudenciais. Acerto da incidência dos juros de mora a contar da citação por se tratar de relação contratual. Correção monetária, todavia, que deve incidir a partir dos desembolsos dos valores pelos autores. Recurso que se nega provimento, com observação.

A recorrente aponta ofensa aos artigos 389, 394 e 402 do Código Civil, alegando que o percentual estabelecido no acórdão não representação indenização dos prejuízos suportados, uma vez que sequer cobre os gastos, inclusive tributos, e as despesas, as quais não podem ser individualizadas por unidade habitacional, devendo ser respeitada a cláusula penal, que fixa a retenção em 40% (quarenta por cento) das prestações quitadas.

Adiciona que sofrerá prejuízo, pois a crise econômica impõe a revenda incerta, por valor inferior, ante a desvalorização do bem imóvel. Ressalta que o imóvel foi vendido em setembro de 2013, quando a demanda imobiliária era farta, e o distrato unilateral ocorreu em abril de 2016, em meio à notória crise financeira que se prolonga até os dias atuais, sendo gigantesco o seu passivo imobiliário, uma vez que há grande

número de ações de distrato por iniciativa dos então compradores.

Aduz que o Judiciário não pode anular as disposições contratuais, considerando que os recorridos adimpliram meramente 14,95% (quatorze inteiros e noventa e cinco centésimos) do bem, sob pena de incentivo, por influência do Judiciário, ao distrato. Aduz que a devolução de apenas 10% (dez por cento) do que foi pago acarretará obrigação de desembolsar valor superior ao recebido da autora, responsável pelo distrato. Isso porque o valor atualizado das prestações pagas (R$ 79.083,43) é inferior ao total que deverá restituir, considerado o acréscimo de juros, custas e honorários de sucumbência, nos termos determinados pelo acórdão recorrido (R$ 92.132,18). Transcreve ementas de julgados estaduais que estabelecem o percentual na metade do montante pago em prestações.

Sustenta que os juros de mora são devidos apenas a partir do trânsito em julgado em decorrência de que a rescisão foi de iniciativa dos adquirentes. Requer o provimento do recurso, com a manutenção da cláusula penal na forma pactuada com a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (fls. 346/350), os recorridos invocam a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, a ausência de demonstração da negativa de vigência dos dispositivos legais e pedem a majoração da verba honorária.

O recurso especial foi admitido na origem (fls. 352/353).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.519 - SP (2018/0023436-5)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE	:	ESSER ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO	:	MAURICIO OZI E OUTRO(S) - SP129931
RECORRIDO	:	MARIA JOSE DANIELI LEITE
RECORRIDO	:	PAULO SERGIO DANIELI LEITE
ADVOGADO	:	JOÃO LUCIO NIEDZIELSKI LEITE E OUTRO(S) - SP306038

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).

2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).

4. Recurso especial parcialmente provido.

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Depreende-se dos autos que os autores desistiram da compra do imóvel e, discordando da cláusula penal convencionada, ajuizaram a presente ação postulando a rescisão do contrato com a restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos e acréscimo de juros legais desde a citação e correção monetária de cada desembolso.

A sentença julgou procedentes os pedidos na forma requerida, condenando a incorporadora ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls. 264/268), o que foi mantido pelo acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos (fls. 316/320):

> Cediço que os autores têm direito a rescindir o contrato. A jurisprudência tem reiteradamente decidido, ainda que o negócio seja desfeito por culpa do comprador, que as partes devem ser restituídas à situação em que se encontravam antes da sua celebração, autorizada a retenção de uma porcentagem pelo fornecedor, a título de cláusula penal, nos termos da Súmula nº 1, editada por este E. Tribunal de Justiça:
>
> > "o compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem".
>
> Consequentemente, o contratante deve assumir o ônus da rescisão, suportando as penalidades rescisórias.
>
> Em casos análogos, esta Colenda 7ª Câmara de Direito Privado vem decidindo que é adequado autorizar que a vendedora retenha entre 10 a 20% daquilo que foi efetivamente pago pelo comprador:
>
> (...)
>
> **No presente caso, a retenção do percentual de 10% mostra-se suficiente para compensar custos operacionais oriundos do desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes, incluindo as alegadas despesas com tributos.**
>
> Acrescente-se que com a entrada em vigor do Código de Defesa

> do Consumidor, a estrita aplicação do princípio da pacta sunt servanda foi mitigado. As partes se enquadram nas definições dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/1990, cuja aplicação tem cunho protetivo.
> Desta forma, é cristalino o direito de o comprador obter a devolução do que despendeu. Todavia, o vendedor tem a prerrogativa de reter parte desse numerário para ressarcimento das despesas administrativas.
> Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que :
>
> > "Reconhecido que o promitente-comprador tem direito à devolução do que foi pago, posto que negado o pleito do autor, no sentido da perda das importâncias correspondentes, as partes haverão de ser repostas no estado anterior. Possibilidade de determinar-se a devolução, sem necessidade de reconvenção."
> > (REsp nº 50.608-5-SP, STJ, 3ª Turma, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJU 20.11.95).
>
> (...)
> Ressalte-se, também, como correto o entendimento do juiz singular ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, por tratar-se de relação contratual (artigo 405 do Código Civil vigente).
> Todavia, tem-se que a correção monetária não deve incidir a contar da data da citação, até o efetivo reembolso pelas rés, como sentenciado, tampouco após o trânsito em julgado como pretende a apelante, razão pela qual corrige-se de ofício, por ser matéria de ordem pública, para que os valores sejam corrigidos a partir do desembolso pelos autores, por ser mera atualização da moeda, adotada a tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça.
> Por fim, diante da reforma mínima da r. sentença, a verba sucumbencial deve ser mantida.
> Posto isto, nega-se provimento ao recurso, com observação. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte autora ficam majorados para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso especial, conforme relatado, questiona o percentual devido pela rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, por iniciativa dos

compradores, e o termo inicial da fluência dos juros de mora sobre a quantia a ser restituída.

Assim posta a controvérsia, recordo que os contratos de compra e venda, promessa de venda ou cessão de unidades autônomas foram concebidos, pelo art. 32 §2º da Lei 4.591/64, como irretratáveis, o que deveria conferir segurança tanto ao empreendedor quanto ao adquirente da futura unidade.

A propósito da irretratabilidade de tais contratos, como característica essencial à regência das incorporações imobiliárias, e do prejuízo causado à coletividade quando há a quebra do sistema, com a desistência unilateral por parte de um dos adquirentes, é elucidativa a doutrina de MELHIM CHALHUB :

> "(...) **Dados o nexo funcional que liga os contratos de alienação das unidades e a dependência da incorporação de suas próprias forças, o direito positivo protege seu patrimônio no interesse comum da coletividade dos contratantes por meio de mecanismos econômicos, financeiros e, até mesmo, processuais destinados a garantir a preservação do fluxo financeiro direcionado à obra e à liquidação do passivo da incorporação, dentre os quais se destacam: (I) blindagem patrimonial mediante constituição de um patrimônio separado, de afetação, para cada incorporação imobiliária (arts. 31-A e ss. da Lei 4.591/1964), (ii) irretratabilidade das promessas de venda (§ 2º do art. 32 da Lei 4591/1964), (iii) blindagem do produto das vendas mediante impenhorabilidade dos créditos oriundos da alienação dos imóveis (art. 833, XII, do novo Código se Processo Civil, Lei 13.105/2015), (iv) procedimento extrajudicial de cobrança e leilão para recomposição do capital da incorporação, em caso de inadimplemento da obrigação dos adquirentes (art. 63 da Lei 4.591/1964), dentre outras normas que vinculam os créditos oriundos das promessas prioritariamente à execução da obra e liquidação do seu passivo.**
>
> (...)
>
> É em conformidade com a caracterização da incorporação imobiliária como unidade econômica autônoma que a Lei 4.591/1964 institui requisitos para a celebração de contratos de alienação das unidades imobiliárias a construir e define elementos de sua peculiar caracterização, visando preservar os recursos destinados ao pagamento das obrigações correntes do negócio.

O contrato empregado com mais frequência para a comercialização desses imóveis é o de promessa de compra e venda, que, no contexto da incorporação imobiliária, é dotada de requisitos específicos, que a distinguem da caracterização genérica do art. 1.417 do CC/2002.

Em primeiro lugar, na incorporação imobiliária esse contrato cumpre duplo papel, de transmissão de direito aquisitivo e de formação do capital da incorporação.

Assim, sua formação, execução e extinção deve atender não somente ao art. 1.417 do CC/2002, mas também aos arts. 28 e ss. da Lei 4.591/1964, naquilo que as normas sobre a incorporação têm de específico.

De fato, o tipo contratual definido pelo art. 1417 do CC/2002 não atende à estrutura e função do modelo de operação econômica de produção e venda de imóveis integrantes de conjuntos imobiliários em construção, e para suprir essa necessidade o legislador criou um tipo peculiar de promessa de venda, que se amolda à funcionalidade econômica e social da incorporação imobiliária, e para esse fim, entre outras especificidades, vincula o produto das alienações ao pagamento do passivo da incorporação.

A essa peculiaridade articula-se a irretratabilidade, que, de uma parte, obriga o incorporador a outorgar o contrato definitivo ao adquirente e lhe assegura o direito à adjudicação compulsória e, de outra parte, sujeita o adquirente que não cumprir o contrato à perda das arras e à indenização das perdas e danos decorrentes da ruptura contrato (art. 419 do CC/2002).

A necessidade de firmeza dos vínculos obrigacionais no contexto da incorporação é de tal relevância que até mesmo o recibo de sinal e o ajuste preliminar para venda são equiparados a negócios de transmissão imobiliária irretratáveis, passíveis de registro no Registros de Imóveis, que confere direito real de aquisição ao adquirente (§ 4º do art. 35).

A irretratabilidade é inerente à natureza peculiar das promessas nesse contexto não somente por conferir proteção patrimonial a cada adquirente, individualmente, mas, também, por constituírem esses contratos, no seu conjunto, fonte de alimentação financeira indispensável para realização da função econômica da incorporação.

É a perspectiva de estabilidade do fluxo financeiro, sinalizada pela irretratabilidade, que infunde no mercado financeiro a confiança na firmeza e na liquidez dos contratos de promessa, encorajando a concessão de financiamento para a construção, garantido pelos créditos nelas constituídos, mediante cessão fiduciária, além de hipoteca ou propriedade fiduciária sobre o terreno e acessões.

A terceira peculiaridade, que distingue a promessa de venda de que trata o art. 1.417 do CC/2002 daquela tipificada nos arts 28 e ss. da Lei 4.591/1964, é o interesse coletivo que vincula os adquirentes, na medida em que, de uma parte, a execução do programa de cada contrato de alienação depende da atuação coordenada dos adquirentes e do incorporador e, de outra parte, as questões de natureza individual são condicionadas pelo interesse comum da coletividade dos adquirentes, dada a função de aporte de capital exercida pela promessa.

Na incorporação imobiliária o conjunto dos adquirentes forma uma coletividade que se vincula por meio de *contratos comunitários* nos quais, como observa Judith Martins-Costa, a noção de comunidade e de coligação subjaz na própria racionalidade econômica-social dessa espécie de atividade empresarial:

“Uma vez que num dos polos não está meramente o interesse de uma soma aritmética de 'individualidades', mas interesses supra-individuais ou coletivos (..), razão pela qual na apreciação desses contratos, os direitos subjetivos de cada um dos contratantes não podem ser vistos ser vistos de modo atomístico, como se cada um fosse uma entidade isolada, envolvida na hobbesiana luta de todos contra todos. Dessa compreensão resulta a afirmação da transindividualidade ou comunitariedade que está no fulcro da operação jurídica e econômica de tais contratos”.

É em razão dessa conexão, justificada pelos “interesses transindividuais ou coletivos”, que os direitos subjetivos de cada um dos promitentes compradores devem ser sopesados em face do interesse comum que vincula a coletividade dos promitentes compradores, pois a realização da função econômica e social dessa espécie de contrato, nesse contexto, mesmo visto sob a perspectiva de um só adquirente, só é concretizada com a participação pecuniária da totalidade dos adquirentes, mediante aporte regular das parcelas do preço conforme a programação do

contrato.

(...)

São também relevantes as questões relativas à mora e ao inadimplemento da obrigação de pagamento pelos adquirentes, seja porque o retardamento de aportes de recursos importa em diminuição do ritmo da obra, em razão da redução do fluxo financeiro a ela direcionado, seja porque a restituição de quantias pagas pelo adquirente inadimplente depende de levantamento de recursos extraorçamentários, que são obtidos mediante revenda da unidade objeto da resolução do contrato.

A existência de regime jurídico especial para a promessa de compra e venda de imóveis integrantes de incorporação imobiliária, dotado de mecanismos destinados à preservação do equilíbrio econômico do contrato, realização da sua função social nesse contexto e proteção do adquirente, justifica atenção especial à singularidade desse negócio jurídico, de modo a evitar que a aplicação arbitrária de normas do CDC, com desprezo do regime instituído pela lei especial, leve a distorções que acabem por prejudicar ou frustrar a realização do objeto da incorporação, em prejuízo da coletividade.

Exemplo típico é o arrependimento, assegurado ao consumidor em relação à compra de coisa móvel, sobretudo por via de telefone ou internet, mas inaplicável à promessa de compra e venda.

O arrependimento não é compatível com a incorporação imobiliária não só porque se contrapõe à irretratabilidade expressamente prevista no art. 32, § 2.º, da Lei 4.591/1964, como, também, porque se opõe à ideologia do próprio CDC, que não admite o desfazimento do contrato senão nos casos nele previstos; é, ainda, inadmissível o arrependimento porque o princípio da conservação dos contratos "é uma das características do CDC, de forma a realizar as expectativas legítimas do consumidor quanto ao ideal de equilíbrio (justiça) contratual" (...) (Revista de Direito Civil Contemporâneo, vol. 7, abril-junho 2016).

Como é sabido, todavia, nos anos que precederam a edição do Código do Consumidor e também nos subsequentes, até a implantação do Plano Real, o surto

inflacionário impactou fortemente o crédito imobiliário, com consequências deletérias para o fornecedor e para o consumidor.

Os financiamentos obtidos na fase da obra perante as próprias construtoras tiveram seu cumprimento dificultado pela hiperinflação, pela imprevisibilidade da evolução das prestações e pelos preços dos insumos das obras.

Diante da insuportabilidade do pagamento das prestações, dada a conjuntura econômica superveniente à data da contratação, era comum a rescisão do contrato, impondo, para tanto, o incorporador a perda total das prestações pagas.

Nesse cenário, o art. 53 do Código do Consumidor veio a afirmar a nulidade das cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

Foi, contudo, vetado o §1º do mesmo artigo, que assegurava ao comprador o direito de requerer o desfazimento do contrato e a devolução das prestações pagas.

Diante da controvérsia a respeito da possibilidade de o comprador desistir do contrato – por lei, irretratável – e requerer a devolução dos valores pagos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da prevalência do princípio imanente ao art. 53 do CDC, coibindo a cláusula padrão inserida nas promessas de compra e venda, que previa a perda das parcelas pagas pelo promissário inadimplente.

Foi reconhecido, inclusive, o direito do consumidor inadimplente de promover ação a fim de receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, de outro lado, o direito de reter parcela do montante. Nesse sentido: REsp. 132.903-SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 19.12.97; EREsp 59.870/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Segunda Seção, DJ 9.12.2002.

Esse direito, a princípio, foi afirmado com base em teorias como imprevisão, modificação do contrato por onerosidade excessiva, alteração da base do negócio. Em precedentes posteriores ao Código do Consumidor, foi considerada a ilegalidade de cláusulas que imponham manifesta desvantagem ao devedor (art. 51, IV e §1º, III), sendo enfatizado que o incorporador e o construtor devem devolver imediatamente o valor pago pelo consumidor, uma vez que podem revender a unidade, eventualmente com lucro.

Assentou a Segunda Seção, com efeito de tese repetitiva, que “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (REsp. 1.300.418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10.12.2013).

Em seguida, a jurisprudência foi consolidada na Súmula 543: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

Nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato partiu do consumidor, sem culpa do fornecedor, ante a ausência de disciplina legal - até a recentíssima edição da Lei 13.786 de 27.12.2018, a qual irá reger futuros contratos - remanesce ainda acesa controvérsia sobre o percentual a ser retido pelo fornecedor.

Anoto que a Segunda Seção, no já citado EREsp 59.870/SP, afirmou o direito do consumidor desistente do contrato a receber 75% dos valores pagos, retendo a construtora, portanto, 25%. Nos debates, o Ministro ARI PARGENDLER enfatizou que a devolução das prestações pagas deve ser feita após a retenção, não apenas das despesas incorridas pelo empreendedor, lembradas pelo Ministro CESAR ASFOR ROCHA, como custos com corretagem, publicidade, ocupação, manutenção, segurança, vigilância, mas também de “uma indenização adicional pelo rompimento do vínculo, porque, se assim não for, estaremos dizendo que a pessoa pode contratar sem se estar obrigando. Quem se obriga e rompe essa obrigação, sofre uma pena”.

Igualmente no REsp. 331.923-RJ, relator o Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, a Quarta Turma, invocando o decidido no EREsp 59.870/SP, decidiu que o desfazimento do contrato dá ao comprador direito à restituição das parcelas pagas, com retenção pelo vendedor de 25% sobre o valor pago, havendo, ainda, no caso específico, em que os compradores usaram o imóvel por considerável tempo, o dever

de ressarcimento a título de aluguéis.

Posteriormente, a Segunda Seção, no julgamento de embargos de divergência, interpretando o decidido no EREsp 59.870/SP, repeliu a tese de que o percentual de 25%, adotado predominantemente na jurisprudência do STJ, já levaria em conta o ressarcimento pela ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel, de forma que, quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deveria ser reduzido o percentual de retenção. Prevaleceu o entendimento de que "o percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento". Concluiu, então, a Segunda Seção pela "continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório." Trata-se do EAg 1.138.183/PE, relator Ministro SIDNEI BENETI, que recebeu a seguinte ementa:

> PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR.
>
> 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo, quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção.
>
> 2.- O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002).
>
> 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e

> cominatório.
> 4.- Embargos de divergência improvidos.
> (EAg 1138183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4.10.2012).

A despeito de uniformizada a matéria pela Seção competente do STJ, e rejeitada a tese de que o percentual de 25% de retenção deve ser diminuído em caso de imóvel que não chegou a ser entregue ao consumidor desistente, há nos dias de hoje enorme dispersão na jurisprudência dos Tribunais Estaduais, havendo alguns deles fixado, como base, o percentual de retenção em apenas 10%, em atenção precisamente à circunstância – repelida para tal fim pela Segunda Seção - de que o imóvel não chegou a ser ocupado pelo desistente. Na maioria dos casos, o percentual de retenção é fixado pelo tribunal de origem de forma aleatória, em 10% 15% ou 20%, desprezando os termos do contrato, com base apenas na jurisprudência (na prática, tabelamento) de cada câmara, em atenção a supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas, no acórdão.

Os recursos especiais sobre a questão não têm obtido acesso ao STJ, no mais das vezes enfrentando o óbice da Súmula 7, sob o argumento de que é compatível com a jurisprudência deste Tribunal o percentual de retenção entre 10 e 25%, e de que as circunstâncias de fato avaliadas na origem seriam insusceptíveis de reexame na via extraordinária.

Nesse sentido, cito: AgInt no AREsp 1393461/GO, Rel. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**, TERCEIRA TURMA, DJe 6.5.2019; AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**, TERCEIRA TURMA, DJe 10.9.2018; AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro **MOURA RIBEIRO**, TERCEIRA TURMA, DJe 15.6.2018; AgRg no Ag no REsp 1349644/MG, Rel. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**, TERCEIRA TURMA, DJe 31.3.2014; AgInt no AREsp 1313870/DF, Rel. Ministra **NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, DJe 3.4.2019; AgInt nos EDcl no REsp 1388755/SC, Rel. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**, QUARTA TURMA, DJe 7.5.2019; AgInt no AREsp 1384313/PE, Rel. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, QUARTA TURMA, DJe 29.3.2019; AgInt no AREsp 1263262/SP, Rel. Ministro **RAUL ARAÚJO**, QUARTA TURMA, DJe 13.3.2019; AgInt no AREsp 1200273/DF, Rel. Ministro **MARCO BUZZI**, QUARTA TURMA, DJe 26.6.2018; AgInt no AREsp 940.397/SP, Rel.

Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**, QUARTA TURMA, DJe 7.12.2016; entre muitos outros.

Tendo votado vencida no EAg 1138183/PE, hoje penso ter sido mais adequado o entendimento da maioria formada à época.

Com efeito, é salutar que haja um padrão-base aceitável de cláusula penal de retenção de valores em caso de desistência de um dos contratantes, na hipótese de ausência de peculiaridade relevante segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Hoje, aliado à disciplina do CDC, o art. 413 do Código Civil não somente permite, mas determina que as cláusulas penais sejam reduzidas pelo juiz, se consideradas excessivas, de acordo com a natureza e a finalidade social e econômica do negócio. Por outro lado, deve haver um mínimo de previsibilidade, pelos contratantes, das consequências de sua iniciativa de não dar prosseguimento ao contrato. A dosimetria da cláusula penal, em casos tais, tem papel importante para a continuidade do empreendimento, na medida em que, de um lado, não se pode incentivar a desistência do adquirente e, por outro, igualmente não deve ser permitido o enriquecimento ilícito do fornecedor. A incorporação imobiliária, como qualquer ramo da atividade econômica, sobretudo aqueles que demandam investimentos e contratos de longa duração, necessita de segurança jurídica para desenvolvimento equilibrado e sustentável da cadeia produtiva.

A circunstância de o imóvel ter ou não sido usufruído pelo comprador desistente não deve, como acertamente decidiu a maioria da Segunda Seção, ser relevante para a definição do percentual justo de retenção a título de cláusula penal. O tempo de uso deve ser indenizado tendo por base o valor locatício de imóvel semelhante multiplicado pelo número de meses em que durou a ocupação. Este é o entendimento mais atual do STJ, valendo lembrar o precedente relatado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, no qual a Quarta Turma estabeleceu que, em caso de rescisão do contrato de compra e venda, independentemente da causa - culpa do fornecedor ou do consumidor - deve haver o pagamento de indenização pela ocupação do imóvel, desde a imissão na posse do comprador, com base no princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp. 955.134/SC, DJe 29.8.2012).

Assim, a garantia ao promitente vendedor do recebimento de indenização pelo tempo em que o promissário comprador desistente ocupou o bem, a fim de evitar

enriquecimento ilícito, não deve ser confundida e englobada no percentual da cláusula penal de retenção em favor do construtor, destinada esta a desestimular e indenizar a rescisão unilateral do contrato. Trata-se de institutos jurídicos distintos, com propósitos e bases econômicas próprias. Leia-se, entre outros, também os acórdãos da 4ª Turma no AgInt no AREsp 191.430/DF, DJe 4.3.2017, o Ag Int. no REsp. 1.167.766-ES e o AgInt no REsp. 1.216.477-RS, de minha relatoria.

À luz do cenário atual - não mais de hiperinflação, mas de grave retração econômica - MELHIM CHALHUB, prossegue, comentando a evolução da jurisprudência do STJ, que, como visto, passou a permitir que o consumidor desista do contrato (irretratável segundo a Lei 4.591/64) e receba imediatamente, em parcela única, os valores pagos:

> "É, sem dúvida, abusiva a cláusula que possibilita a revenda da unidade e não obrigue o incorporador a destinar parte do produto aí obtido ao promitente comprador retirante.
> Entretanto, não tem sido considerada a necessidade de adequação da liquidação do crédito do inadimplente à conformação peculiar da incorporação – notadamente a exigência legal de controle orçamentário -, e esse é aspecto de relevante importância na ponderação dos interesses em jogo – em atenção aos princípios do equilíbrio e da função social do contrato -, que justifica um esforço de construção jurisprudencial, visando "o melhor resultado coletivo e não apenas o interesse isolado de um demandante específico, como observa o Desembargador Werson Rego, do TJRJ:
>
> > "Estimular o julgador a entender que a decisão dele tem repercussão nas atividades econômicas e levando-o à reflexão sobre a importância dos julgamentos levarem segurança jurídica, estabilidade e paz aos mercados. As decisões têm que buscar, tanto o quanto possível, o melhor resultado coletivo e não apenas o interesse isolado de um demandante específico. O julgador tem que saber como o mercado interpreta uma decisão judicial. Se julgarmos contra a regra aumentamos os riscos nos mercados, que vão se proteger. E como? Embutindo o risco nos preços dos serviços e produtos. No final, quem pagará a fatura é o consumidor. Quando se pensa estar protegendo um consumidor ao dar a ele uma proteção jurídica sem um efetivo direito, esta conta

> será dividida com todos os consumidores daquele mercado. Então, surge a pergunta: será que os outros consumidores, sabendo disso, vão querer pagar esta conta ou vão preferir que o juiz seja rigoroso na análise de quem tem ou não razão?

Com efeito, a questão do desfazimento das promessas de venda de imóveis integrantes de incorporações imobiliárias não se esgota na apreciação das questões de fato e de direito contidas no limitado campo da relação jurídica constituída pelo incorporador e pelo adquirente demandante.

A decretação do desfazimento e a definição de critério de liquidação do eventual crédito do inadimplente são apenas parte do problema e não o solucionam por inteiro, porque os efeitos da ruptura do contrato de promessa extrapolam os limites da relação jurídica individual e atingem o interesse comum da coletividade dos contratantes da incorporação.

Esses efeitos, contudo, não têm sido considerados na construção da jurisprudência dominante, apesar de prejudicarem o interesse da coletividade dos contratantes, pois, na medida em que o inadimplemento importa em diminuição do capital da incorporação imobiliária, o cumprimento do seu objeto dependerá de recomposição do seu fluxo financeiro, que, por sua vez, depende da revenda da unidade objeto da resolução, pois o lastro para formação do capital da incorporação limita-se ao número de unidades do empreendimento.

Além desse aspecto específico, há outras questões relacionadas ao desfazimento de promessas na incorporação imobiliária, que compõem o problema como um todo, e não chegaram a ser considerados nos precedentes da Súmula 543.

Merece também atenção o desfazimento imotivado de promessa de compra e venda com fundamento em simples manifestação de arrependimento do promitente comprador, com desprezo à irretratabilidade definida pela Lei 4.591/1964.

Situação igualmente merecedora de atenção é a do promitente comprador-investidor, que adquire o imóvel "na planta" com o propósito de revendê-lo com lucro por ocasião do "habite-se" ou de auferir renda de locação; sucede que em situações de crise (como a que ocorre nos anos 2014/2015), ao ver frustrada sua expectativa de lucro,

> **seja pela não valorização em conjuntura desfavorável ou por falta de liquidez no mercado, o promitente comprador-investidor simplesmente desiste do investimento e busca o desfazimento imotivado do contrato.**
> **Há também situações em que se dá a resolução da promessa por não reunir o adquirente as condições de renda ou de cadastro de crédito para obtenção de financiamento para pagamento do saldo do preço.**
> Essas e outras situações envolvendo o contrato de promessa de compra e venda não foram objeto dos precedentes da Súmula 543, mas merecem atenção.
> (...)
> **Pode ocorrer que alguns adiram à incorporação e, se o mercado não for favorável para a atividade imobiliária, exijam a restituição do que pagaram, com juros e correção monetária, tal como se a aplicação tivesse sido feita em caderneta de poupança."** (grifos não constantes do original).

Com efeito, nos anos mais recentes, debelada a inflação, a crise é causada pela estagnação da economia. Vivemos, como é notório, época de seríssima crise econômica. O mercado imobiliário, dada a necessidade de segurança nos investimentos de grande vulto e longo prazo, é particularmente sensível.

A retração do mercado imobiliário é revelada no estoque de imóveis vazios, em busca de interessados na compra ou aluguel. A revenda do imóvel, nos dias atuais, em caso de desistência imotivada do comprador pode não ser lucrativa como já foi no passado. Não é difícil imaginar a dificuldade do empreendedor em, no curso da obra, não apenas não mais contar com o fluxo de recursos do comprador desistente, mas ainda ter que devolver todo o valor pago – já presumivelmente investido na obra – imediatamente, com juros e correção.

A retenção apenas de 10% dos valores pagos pelo comprador, com a devolução do restante imediatamente, antes da revenda da unidade em construção, se não é um problema em época de mercado aquecido, podendo até mesmo gerar lucros para o fornecedor, se houve valorização, pode conduzir à inviabilidade do empreendimento, em época de crise.

A rescisão unilateral do contrato não deve ser vista como direito potestativo, infenso a qualquer conseqüência significativa para desistente, e muito

menos como investimento financeiro para o adquirente. O desfazimento do contrato não deve se tornar, artificialmente - mercê de mal aplicadas interpretações jurisprudenciais, surgidas em contexto que as justificavam e para finalidades diversas - mais interessante do que o cumprimento do contrato com a finalidade social a que se destinava: aquisição da unidade imobiliária.

A proteção do interesse dos consumidores, portanto, deve ser exercida de forma equilibrada, sem descurar da coletividade, o que ensejará a sustentabilidade e a estabilidade entre os interesses envolvidos na incorporação imobiliária.

Assim, tenho que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promissário comprador - percentual consolidado pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE - é adequada e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato, independentemente da ocupação da unidade imobiliária.

Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.

Enfatizo que o referido percentual, sob a perspectiva da segurança jurídica, representa uma sinalização aos contratantes, a orientação de padrão-base aceitável de cláusula penal de retenção de valores em caso de desistência imotivada pelo comprador, cujo limite deve ser observado, sob pena de intervenção na autonomia da vontade das partes. A estipulação dentro do limite proposto, vale dizer, de no máximo 25%, a *contrario sensu*, deve ensejar respeito à vontade dos contratantes, caso não seja efetivamente demonstrada a existência de abusividade, por qualquer circunstância específica, particular, a qual deve ser mencionada pelo tribunal de origem para fugir ao percentual estabelecido no contrato e ao parâmetro da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Segunda Seção, EAg 1.138.183/PE).

Observo que a Lei 13.786/2018, suprindo a lacuna do direito positivo, e incorporando ao direito positivo diversos entendimentos e parâmetros já consagrados pelo STJ, adotou o percentual 25% da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação (arts. 67-A, inciso I e §5º).

A aplicação de tais lineamentos nos julgamentos efetuados por esta

Corte, mormente em razão da fixação de percentuais de maneira padronizada pelas instâncias ordinárias, sem apoio de circunstâncias do caso concreto, não demanda reexame probatório.

No presente hipótese, conforme se extrai dos autos, esse limite foi ultrapassado, pois o contrato celebrado entre as partes prevê a devolução de apenas 40% (quarenta por cento) dos valores pagos.

O acórdão recorrido reduziu o percentual pactuado para 10% (dez por cento) sem mencionar circunstância alguma peculiar que justifique fugir ao parâmetro traçado pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE.

Com efeito, nada disse o acórdão a respeito do valor dos custos incorridos pela empresa ré e nem os contrapôs às quantias efetivamente pagas pelos autores e nem ao valor do contrato. Nada mencionou a respeito das circunstâncias do mercado. Nenhuma justificativa, baseada no específico contrato dos autos ou em fatos da causa, foi dada pelo padronizado acórdão recorrido para glosar a cláusula contratual e, além disso, estabelecer o percentual de 10%, inferior ao parâmetro consolidado no EAg 1.138.183/PE.

Entendo, portanto, deva prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, afirmado por esta 2ª Seção Corte como parâmetro suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e compensá-lo do rompimento unilateral do contrato.

O pleito reformatório procede também quanto ao termo inicial dos juros de mora.

É firme o entendimento desta Corte no sentido de que “na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão” (Quarta Turma, REsp 1.211.323/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 20.10.2015).

Ainda nesse sentido:

> AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO DO ART.396 DO CC. TERMO

INICIAL DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.PRECEDENTES.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior sufragou o entendimento de que, "na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.008.610/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 03.09.2008)
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no REsp 1.354.293/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15.9.2014);

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL.SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o termo inicial dos juros de mora na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador é a data do trânsito em julgado da decisão.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 474.503/MG, QUARTA TURMA, de minha relatoria, DJe 17.9.2014);

CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.RESOLUÇÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE-COMPRADOR INJUSTIFICADAMENTE.PARCELA A SER RESTITUÍDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE FLUIÇÃO.TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

> II. Inexistência de mora anterior da ré.
> III. Recurso especial conhecido e provido.
> (REsp 1.008.610/RJ, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 3.9.2008).

Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com restituição de valores em desconformidade do que foi pactuado.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para fixar em 25% (vinte e cinco por cento) a retenção sobre os valores pagos pelos autores, que deverão ser restituídos com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em razão da sucumbência recíproca, arcarão os autores com 40% (quarenta por cento) e a ré com 60% (sessenta por cento) do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.519 - SP (2018/0023436-5)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE	:	ESSER ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO	:	MAURICIO OZI E OUTRO(S) - SP129931
RECORRIDO	:	MARIA JOSE DANIELI LEITE
RECORRIDO	:	PAULO SERGIO DANIELI LEITE
ADVOGADO	:	JOÃO LUCIO NIEDZIELSKI LEITE E OUTRO(S) - SP306038

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Discutem-se no presente recurso especial duas questões, essencialmente: o percentual de retenção a que o promitente vendedor faz jus na hipótese de desistência do negócio pelo promitente comprador e o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre valor a ser restituído.

A eminente Relatora, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em seu voto, propõe a adoção de um padrão único equivalente a retenção de 25% dos valores pagos pelo promitente vendedor, pois salutar que haja uma cláusula penal uniforme e aplicável a todas as hipóteses, que assegure maior previsibilidade aos contratantes.

Além disso, não seria possível autorizar uma retenção maior ou menor de valores como forma de indenizar o promitente vendedor pelo tempo que, eventualmente, tenha o promitente comprador ocupado o imóvel. Segundo assinalado, o enriquecimento ilícito que poderia advir desse tipo de situação, deve ser evitado pelo arbitramento de indenização específica, com natureza distinta da cláusula penal.

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, Sua Excelência adotou a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que referido encargo deve fluir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que condenou o promitente vendedor à restituição de valores em percentual distinto daquele previsto no contrato.

Pedi vista dos autos porque a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora era debatida no REsp nº 1.740.911/DF, afetado como repetitivo e que estava sob minha relatoria, mostrando-se oportuno aguardar a formação daquele precedente qualificado, antes de julgar, neste processo, a mesma questão.

O julgamento do REsp nº 1.740.911/DF encerrou-se na sessão do dia 14/8/2019 com a adoção do mesmo entendimento ora proposto pela eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, no sentido de que os juros de mora devem fluir apenas a partir

do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assim, considerando o efeito vinculante do entendimento lá fixado com relação ao tema e a conveniência de se adotar um padrão-base para a cláusula penal no contrato de promessa de compra e venda, equivalente a 25% dos valores pagos pelo promitente comprador, acompanho o bem lançado voto proferido pela eminente Relatora, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.

Ressalvo, no entanto, que o entendimento adotado somente tem aplicação aos contratos firmados antes do início de vigência da Lei nº 13.786/2018.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2018/0023436-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.723.519 / SP**

Números Origem: 10421042520168260100 20170000328025

PAUTA: 22/05/2019 JULGADO: 22/05/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. SADY D´ASSUMPÇÃO TORRES FILHO

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	ESSER ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO	:	MAURICIO OZI E OUTRO(S) - SP129931
RECORRIDO	:	MARIA JOSE DANIELI LEITE
RECORRIDO	:	PAULO SERGIO DANIELI LEITE
ADVOGADO	:	JOÃO LUCIO NIEDZIELSKI LEITE E OUTRO(S) - SP306038

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Promessa de Compra e Venda

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sra. Ministra Relatora conhecendo do recurso e a ele dando parcial provimento, pediu VISTA antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2018/0023436-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.723.519 / SP**

Números Origem: 10421042520168260100 20170000328025

PAUTA: 28/08/2019 JULGADO: 28/08/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. SADY D´ASSUMPÇÃO TORRES FILHO

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	ESSER ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO	:	MAURICIO OZI E OUTRO(S) - SP129931
RECORRIDO	:	MARIA JOSE DANIELI LEITE
RECORRIDO	:	PAULO SERGIO DANIELI LEITE
ADVOGADO	:	JOÃO LUCIO NIEDZIELSKI LEITE E OUTRO(S) - SP306038

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Promessa de Compra e Venda

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Moura Ribeiro com parcial ressalva de entendimento, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Marco Aurélio Bellizze, a Seção, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Marco Aurélio Bellizze acompanharam o Sr. Ministro Moura Ribeiro em parcial ressalva de ponto de vista.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.